Superintendencia de Sociedades

SENTENCIA

Superintendencia de Sociedades **Bogotá, D.C.**

Partes

Claudia Marcela Gómez Vásquez

contra

Promotora La Alborada S. A

Asunto
Artículo 137 de la Ley 446 de 1998

Trámite
Proceso verbal sumario

I. ANTECEDENTES

Al haberse verificado el cumplimiento de lo previsto en los artículos 101, 432 y 439 del Código de Procedimiento Civil y por virtud de lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley 446 de 1998, el Despacho se dispone a proferir sentencia.

II. LA DEMANDA

Por medio de apoderado especial, la señora Claudia Marcela Gómez Vásquez, en su condición de accionista de la compañía que gira bajo la razón social de Promotora La Alborada S.A. en acuerdo de reestructuración, presentó demanda de impugnación en contra de una de las decisiones adoptadas en la sesión celebrada el 18 de julio del 2008, de que da cuenta el Acta no. 20 (enumerada erróneamente con el número 19), relacionada con la reforma del artículo Décimo Cuarto de los estatutos sociales de la compañía.

A. Hechos

1. La sociedad demandada no negocia sus acciones en el mercado público de valores.
2. El artículo Décimo Cuarto de los estatutos sociales de Promotora La Alborada S.A. consagra las reglas para la negociación de acciones. En este artículo se establece que el procedimiento allí previsto sólo podrá dejarse de observar cuando se determine mediante el voto favorable de la totalidad de los accionistas.
3. En la reunión objeto de este proceso, se determinó reformar el citado artículo Décimo Cuarto mediante el voto positivo de accionistas que representaron el 96.14% de las acciones suscritas de la compañía y el 99. 96% de las acciones representadas en la reunión correspondiente, según consta en el Acta no. 20, citada.
4. La demandante no asistió a la reunión extraordinaria antes mencionada, conforme a lo expresado en el Acta no. 20.

5. La reforma de los estatutos sociales de Promotora La Alborada S.A. fue inscrita en la Cámara de Comercio del domicilio social los días 22 y 29 de julio de 2008, tal como aparece del certificado de existencia y representación legal expedido por esa entidad.

II. Pretensiones

La demandante formuló ante este Despacho las siguientes pretensiones:

´Que de conformidad con lo establecido por el artículo 190 del Código de Comercio, es absolutamente nula la decisión tomada por la Asamblea de Accionistas de Promotora la Alborada S.A., en reestructuración, en la reunión extraordinaria del día 18 de julio de 2008 por medio de la cual se decidió reformar el artículo Décimo Cuarto de los estatutos sociales y de la que da cuenta el numeral 5 del Acta No. 20 (erróneamente numerada como 19), en la que se dejó constancia de lo acaecido en dicha reunión.

´Que como consecuencia de la declaración precedente, se ordena la inscripción de la parte resolutiva de la sentencia en el registro mercantil, tal como lo previene el artículo 192 del Código de Comercio'

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

La parte actora fundamenta la demanda en lo previsto en los artículos 137 de la Ley 446 de 1998; 190, 191 y 192 del Código de Comercio; artículo 1º del Decreto Reglamentario 4350 del 2006 y 421, 435, 436, 437, 438, 439, 440 y concordantes del Código de Procedimiento Civil.

IV. TRAMITE PROCESAL

Mediante Auto No. 480-014480 del 28 de julio de 2009, se admitió la demanda de la referencia, la cual le fue notificada personalmente al apoderado de la sociedad Promotora La Alborada S. A el 24 de marzo de 2010.

V. CONTESTACIÓN DE DEMANDA

Mediante Auto 480-005525 del 20 de abril de 2010, este Despacho tuvo por contestada la demanda por parte de la sociedad Promotora La Alborada S. A, quién se opuso a cada una de las pretensiones presentadas por la señora Claudia Marcela Gómez Vásquez, y formuló la siguiente excepción de mérito:

1. Validez de la decisión

El apoderado de la sociedad demandada se refiere primero a las reglas en materia de nulidad de las decisiones sociales, para lo cual trascribe los artículos 190, 899 y 191 del Código de Comercio. En este sentido, se afirma que, como el demandante sostiene que la decisión consistente en reformar los estatutos

sociales es nula, debido a que no se adoptó con la totalidad de los votos requeridos para ello, corresponde establecer de acuerdo con la ley y los estatutos, cual es la mayoría para este tipo de decisiones. El apoderado de la compañía demandada también trascribe el artículo 68 de la Ley 222 de 1995 y los artículos vigésimo tercero y vigésimo cuarto de los estatutos sociales de Promotora La Alborada S.A. Por lo demás, se aduce que la determinación impugnada fue aprobada con una mayoría decisoria del 99,96% de las acciones representadas en la reunión, sobre un quórum del 96,17% de las acciones suscritas de la sociedad.

VI. PRUEBAS

Para efectos de emitir este pronunciamiento, el Despacho analizó las pruebas sometidas a su consideración durante el desarrollo del proceso, incluidas las pruebas documentales aportadas con la demanda y la contestación de la sociedad Promotora La Alborada S. A.

VII. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

A. Claudia Marcela Gómez Vásquez

1. El apoderado de la demandante realiza un análisis de las legitimaciones tanto activa como pasiva, hace una referencia al artículo 4º del Código de Comercio para decir que las estipulaciones de los contratos válidamente celebrados preferirán a las normas supletorias y a las costumbres mercantiles, y que el contrato social contenido en la Escritura Pública número 1217 del 24 de abril del año 1992, es válido, y rige para las partes. Además, que los contratos en materia mercantil han de ser interpretados conforme lo establece el artículo 822; en la remisión que hace el Código de Comercio al Código Civil nos permitimos decir que la interpretación de los contratos deberá hacerse de acuerdo con lo establecido por los artículos 1618 a 1624 de la referida obra, en la cual se destaca como principio fundamental de interpretación de los contratos de derecho privado la prevalencia de la intención que hayan tenido las partes más que al sentido literal de las palabras que se contengan en los documentos por ellas suscritos; si la intención no fuera conocida de manera tal que permita interpretarlos con la claridad suficiente se establecen en los artículos subsecuentes al 1618 mencionado otras normas de interpretación supletorias dentro de las cuales resaltamos la interpretación lógica que está contemplada en el artículo 1620, y el de la interpretación sistemática de que las cláusulas de un contrato se interpretaran unas por otras dándose a cada una el sentido que mejor se convenga al contrato en su totalidad.

2. Agrega que con base en las normas citadas se presentó la demanda en virtud de la cual se solicitó que se declare como absolutamente nula la decisión adoptada en la reunión celebrada por Promotora La Alborada el

día 18 de julio de 2008, por medio de la cual se decidió reformar el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales. Artículo que contemplaba unas reglas para la negociación de acciones y establecía en su parágrafo segundo que el procedimiento allí previsto solamente podría dejar de observarse cuando la asamblea de accionistas tomara la decisión por unanimidad de los votos, es clara la intención que tenían las partes al celebrar el contrato social, en respecto a evitar que dicho artículo fuera modificado como se hizo en la reunión que se cuestiona. No tiene sentido que se pacte una determinación que deba tomarse por unanimidad si esa determinación puede dejarse sin efecto con la aplicación de unas mayorías pactadas en otra norma que establece número menor al porcentaje cien por ciento de los asociados para reformar ese mismo artículo; por consiguiente dicha norma no podía ser reformada sino por la unanimidad de los accionista de la demandada, para proteger a los accionistas minoritarios dentro de los cuales se encuentra la demandante.

B. Promotora La Alborada S. A.

1. El apoderado de la sociedad demandada manifiesta que la pretensión sobre la cual se va a ocupar la Superintendencia es fundamentalmente si la decisión de reformar los estatutos es nula o no es nula.

2. Los hechos que se encuentran probados dentro del proceso: 1) que el 18 de julio de 2008 se reunió de manera extraordinaria la asamblea de accionistas de Promotora La Alborada S.A. en acuerdo de reestructuración 2) está probado también que en dicha reunión estuvieron representados el 99.16% de las acciones suscritas y pagadas 3) que la asamblea tomo la decisión de reformar los artículos 14 y 58 de los estatutos sociales 4) las decisiones anteriores fueron votadas afirmativamente por un número plural de accionistas que representaban 52.158.373.105 acciones suscritas equivalentes al 96.14% de la totalidad de las acciones suscritas y al 99.96% de las acciones presentes en la reunión 5) que el artículo 23 de los estatutos sociales establece que la asamblea deliberará con un número plural de personas que tenga o represente por los menos el 75% de las acciones suscritas 6) que el artículo 24 de los estatutos sociales establece que las decisiones sociales se adoptaran por lo menos con el 75% de las acciones representadas en la respectiva reunión salvo disposición estatutaria o legal que establezca una mayoría superior.

3. Cuáles son las razones jurídicas que dan lugar a desestimar las pretensiones: 1) el objeto de este proceso es discutir la validez de una decisión tomada por una asamblea de accionistas; la parte actora circunscribe el objeto del litigio a la validez de una decisión social, sobre esa base ese es el marco tanto de competencia de la Superintendencia como del marco del juez en la sentencia, es decir, una decisión de

reformar los estatutos. El objeto del proceso es discutir la validez de una decisión tomada por la asamblea el 18 de julio del 2008. En ese mismo sentido si se examina el acta 19 que está aportada al proceso se encuentra lo siguiente: la decisión de la asamblea fue reformar un artículo de los estatutos, que regulaba el derecho de preferencia, sí, pero se reformaron fueron los estatutos y allí, de manera expresa, se dice, el doctor Mauricio Valenzuela 'tomó la palabra para preguntar a los asistentes si había alguna propuesta de reformar el artículo décimo cuarto de los estatutos. El doctor Hernán Rodríguez Arenas propuso a la asamblea modificar el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales, facilitando la negociación y la libertad de los accionistas de negociar sus acciones sin sujeción al derecho de preferencia', que fue votada dicha reforma en la forma en que se encuentra consignada en el acta número 19.

4. Por consiguiente, la decisión de la asamblea fue reformar los estatutos sociales y no autorizar una negociación de acciones, resaltando que la asamblea no adoptó ninguna decisión respecto a una determinada negociación de acciones. La decisión de la reforma es válida por cumplir los requisitos legales.

5. A continuación trae a colación el artículo 190 de los estatutos sociales, para significar que la parte actora plantea la nulidad absoluta de la decisión de reformar los estatutos sociales en lo referente al derecho de preferencia, siendo el objeto de este proceso es la legalidad de dicha decisión.

6. El artículo décimo cuarto de los estatutos, habla sobre las reglas para la negociación de acciones, el artículo décimo segundo habla sobre derecho de preferencia en caso de suscripción, es decir, se trata de dos fenómenos distintos al interior de una sociedad anónima; una, los nuevos aumentos de capital autorizado y las consecuentes emisiones que se deban hacer que está gobernado en el artículo décimo segundo que acá no se está discutiendo, que corresponde a los derechos de todos los accionistas de mantener su proporción en el capital, y el artículo décimo cuarto que se refiere a la negociación de acciones, son dos fenómenos jurídicos distintos, uno la suscripción y otro la negociación, por eso no se pueden mostrar como equivalentes porque la misma disciplina legal los distingue, de hecho, para que las acciones en una sociedad anónima la regla general es que son libremente negociables, y por consiguiente se puede restringir esa regla con pacto expreso, no sucede lo mismo con la suscripción porque por mandato legal opera la suscripción porque apunta al estatus socio.

7. En conclusión, se está frente a una decisión que no adolece de nulidad absoluta, no viola la ley, no viola norma imperativa, no tiene objeto ilícito y

fue adoptada de acuerdo con las mayorías dispuestas por el estatuto social vigente.

VIII. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Según las consideraciones sometidas a consideración del Despacho, se tiene que el litigio objeto del presente fallo alude, de modo específico, a la decisión del máximo órgano social de Promotora La Alborada S.A. en el sentido de suprimir de los estatutos de la compañía la cláusula del derecho de preferencia en la enajenación de acciones. La demandante le solicita al Despacho que declare la nulidad de tal decisión, por cuanto, en su criterio, los votos emitidos por los accionistas de aquella sociedad durante una reunión extraordinaria de la asamblea general, resultaron insuficientes para aprobar una decisión de la naturaleza indicada. Así, pues, debido a que la controversia presentada ante el Despacho versa exclusivamente sobre la validez jurídica de la decisión a que se ha hecho referencia, es procedente efectuar un análisis de esta determinación a la luz de las normas que rigen la materia. Para el efecto, se tendrán en cuenta no sólo las reglas sobre la nulidad de decisiones sociales, sino también las normas legales y estatutarias que rigen la adopción de determinaciones en el seno del máximo órgano social de Promotora La Alborada S.A.

Lo primero que debe señalarse es que las pretensiones de la parte demandante están fundamentadas en la causal de nulidad consagrada en el artículo 190 del Código de Comercio, a cuyo tenor, 'las [decisiones] que se adopten sin el número de votos previstos en los estatutos o en las leyes, o excediendo los límites del contrato social, serán absolutamente nulas'. Es así como, en criterio de la demandante, la decisión de modificar los estatutos sociales de Promotora La Alborada S.A. con el fin de suprimir el derecho de preferencia en la enajenación de acciones, requería el voto unánime de la totalidad de los accionistas de la compañía. Para justificar esta última afirmación, la demandante pone de presente la regla contenida en el parágrafo segundo del artículo Décimo Cuarto de los estatutos de esta sociedad, por virtud del cual, 'el procedimiento [del derecho de preferencia en la enajenación de acciones] no tendrá que ser observado cuando la Asamblea de Accionistas, mediante decisión tomada por unanimidad de votos, autorice una determinada negociación de acciones'. En este sentido, según la información aportada por las partes, la asamblea general de accionistas de la Promotora La Alborada S.A. determinó reformar el citado artículo Décimo Cuarto, mediante el voto positivo de accionistas que representaban el 96.14% de las acciones suscritas de la compañía y el 99.96% de las acciones presentes en la respectiva reunión, según consta en el Acta no. 20 del 18 de julio de 2008.

Para efectos de determinar si el Despacho debe acoger las pretensiones del demandante, es indispensable analizar la naturaleza de la decisión impugnada. Según lo consignado en el Acta no. 20 antes mencionada, la decisión consistió en una reforma estatutaria del artículo Décimo Cuarto de los estatutos sociales de Promotora La Alborada S.A., presentada para '[facilitar] la negociación y la libertad de los accionistas de negociar sus acciones, sin sujeción a un trámite de derecho de preferencia'. Por este motivo, la propuesta sometida a

consideración de la asamblea buscó reemplazar el texto del artículo Décimo Cuarto, en el cual se consagraba el derecho de preferencia en la enajenación de acciones, por el siguiente enunciado: 'Las acciones de la sociedad son libremente negociables'.

En este punto, el Despacho considera necesario poner de presente que la decisión del máximo órgano de Promotora La Alborada S.A. no estaba orientada a la renuncia del derecho de preferencia respecto de una operación de compra o venta de acciones. Ciertamente, ni en el texto del Acta no. 20, ni en la demanda presentada ante este Despacho, se menciona la existencia de negocios jurídicos que pudieran haber generado la necesidad de darle curso al trámite del derecho de preferencia en el momento en que se adoptó la decisión impugnada. Es decir que, según se expresó antes, la presente controversia no está relacionada con la renuncia al derecho de preferencia en hipótesis de negociación de acciones, sino, más bien, a la supresión de esta prerrogativa de los estatutos de Promotora La Alborada S.A.

Esta última observación resulta fundamental para dirimir la controversia objeto de este litigio. Ello se debe a que las reglas que rigen una reforma estatuaria orientada a eliminar la cláusula que consagra el derecho de preferencia en la enajenación de acciones, son bien diferentes de aquellas que regulan la renuncia a esta prerrogativa por parte de los accionistas. Debe recordarse que la preferencia en la enajenación de acciones es simplemente un derecho de contenido económico, que puede establecerse en los estatutos de una compañía a favor de los accionistas o de la misma sociedad.[1] Esta prerrogativa sólo encuentra su manifestación plena cuando exista una oferta (o algún otro acto o negocio jurídico) que pueda dar lugar a una transferencia de acciones. En criterio de Martínez Neira, 'el derecho de preferencia en las negociaciones de acciones constituye una mera expectativa, un derecho abstracto que solamente se concreta como derecho cierto cuando un accionista ofrece en venta sus acciones, momento a partir del cual el derecho entra a formar parte del patrimonio del destinatario de la oferta […]. En otros términos, como es evidente, mientras ningún socio ofrezca sus acciones en venta, los consocios carecen de derecho alguno a exigirle a alguno de ellos que le transfieran sus acciones'.[2]

La anterior explicación sobre la naturaleza del derecho de preferencia en la enajenación de acciones es importante para determinar el procedimiento que han de seguir los asociados con el fin de prescindir de este derecho. Es así como, por tratarse de una prerrogativa de contenido económico en cabeza de los accionistas de la compañía, le corresponde a cada uno de tales sujetos renunciar a este derecho, una vez la preferencia adquiera plena vocación jurídica, es decir, en el momento de presentarse una oferta. Ello puede hacerse mediante una renuncia expresa manifestada por un accionista luego de haberse concretado el derecho de preferencia a su favor o mediante el simple rechazo de la oferta respectiva. Por lo

[1] La operación del derecho de preferencia en la negociación de acciones requiere una mención expresa en los estatutos sociales en el sentido de conferirle esta prerrogativa a los accionistas, a la sociedad o a ambas partes.

[2] NH Martínez Neira, Cátedra de Derecho Contractual Societario: Regulación comercial y bursátil de los actos y contratos societarios, (Bogotá, Abeledo Perrot, 2010) 504.

demás, nada obsta para que esta renuncia se produzca en el seno del máximo órgano social, siempre que todos los accionistas titulares del derecho de preferencia así lo dispongan. En este sentido, Reyes Villamizar considera que 'el derecho de preferencia en la transferencia de acciones, como prerrogativa económica en favor de los accionistas es, esencialmente, renunciable. La renuncia a tal derecho debe provenir de un acto individual del accionista destinatario de una oferta de venta, bien mediante su decisión expresa o manifestada en forma tácita, de no aceptar la oferta, o por medio de una decisión colectiva expresada en votación unánime de todos los accionistas reunidos en asamblea general, en la cual se autoriza al accionista enajenante para que proceda a ceder sus acciones a un tercero adquirente no cobijado por el derecho preferencial mencionado'.[3]

A la luz de lo anterior, debe concluirse que la regla establecida en el parágrafo segundo del artículo Décimo Cuarto de los estatutos de Promotora La Alborada S.A. aludía a la 'decisión colectiva' de los accionistas, en el sentido de renunciar al derecho de preferencia respecto de una operación específica. Esta interpretación guarda coherencia con el texto del artículo Décimo Cuarto, citado, en el que se hacía referencia a 'una determinada negociación de acciones'. En otras palabras, el aludido parágrafo segundo no establecía una mayoría decisoria calificada para suprimir la cláusula que consagraba el derecho de preferencia, sino que simplemente reconocía la posibilidad con la que contaban los accionistas titulares de esta prerrogativa de renunciar a ella en el curso de una reunión del máximo órgano social.

Ahora bien, debe reiterarse que la decisión impugnada por la demandante consistió en una reforma estatutaria orientada a modificar el texto del artículo Décimo Cuarto de los estatutos sociales de Promotora La Alborada S.A. Es por ello por lo que la adopción de tal reforma debía ceñirse a las reglas que rigen esta clase de decisiones. En este sentido, en el artículo Vigésimo Cuarto de los estatutos de la compañía se establece una mayoría calificada para las determinaciones del máximo órgano social, por cuyo efecto, 'para la validez de las decisiones de la Asamblea, se requiere el voto favorable de por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones representadas, salvo en los casos en que la Ley y los presentes Estatutos exijan mayoría diferente'. En consecuencia, al haberse adoptado la reforma estatutaria impugnada mediante un porcentaje de votos positivos equivalente al 99.96% de las acciones representadas en la respectiva reunión, el Despacho concluye que esta determinación sí se ajustó a lo previsto sobre el particular en los estatutos sociales de Promotora La Alborada S.A..[4]

Por lo demás, debe traerse a colación un reciente pronunciamiento del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en el que se llega a una conclusión similar a la expresada por este Despacho, en el contexto de una

---

[3] FH Reyes Villamizar, Derecho Societario, Segunda Edición, Tomo I, (Bogotá, Editorial Temis, 2006) 404-405.

[4] No está de más mencionar que en la reunión aludida también se cumplió con la regla estatutaria que establece un quórum del 75% de las acciones suscritas para las deliberaciones de la asamblea general de accionistas de Promotora La Alborada S.A. (cfr. artículo Vigésimo Tercero de los estatutos de la compañía).

demanda de impugnación interpuesta por otro accionista de Promotora La Alborada S.A. en contra de la reforma estatutaria *sub examine*. Mediante sentencia del 11 de julio de 2012, la Sala Civil del referido Tribunal expresó lo siguiente:

> 'Si bien es cierto, que para poder ejercer la venta libre de las acciones era necesaria una decisión por unanimidad, esto solo ocurría dentro de dicho evento, es decir era una situación especial, exclusiva y que solo se aplicaría en los casos indicados en esa norma anterior, es decir, que ese quórum era para un evento específico, cuando estuviera en la venta y compra de acciones, pero no significaba que para modificar dicha norma o reformarla también era aplicable dicho quórum, luego también era aplicable la norma general de la reforma de los estatutos, tal y como se hizo. En cuanto a la interpretación de los contratos, precisamente debe acudirse a ellos en el momento en que se toman las decisiones, que si bien para la época en que se elaboraron los estatutos tenía como fin limitar la negociación libre de las acciones, al modificarlos, como ahora ocurrió al introducir la reforma del artículo catorce, lo que se hacía deliberando con el 75% de los socios y aprobándolo con el 75% de las acciones representadas, la mencionada protección especial dejó de regir. De lo anterior se puede colegir que la reforma realizada a los estatutos cumplió con lo establecido en los mismos y en la ley y por lo tanto es válida.'

A la luz de las anteriores consideraciones, el Despacho deberá desestimar las pretensiones formuladas por la demandante.

II. Respecto de la excepción de mérito formulada por Promotora La Alborada S. A

Por virtud de las consideraciones efectuadas en el acápite anterior, la excepción formulada por el apoderado de la sociedad demandada está llamada a prosperar.

III. Condena en costas

De conformidad con lo establecido en los numerales primero y segundo del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso. Por consiguiente, se fijará como agencias en derecho la suma de $ 1,269,000.

En mérito de lo expuesto, el Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

Primero. Negar las pretensiones de la demanda.

Segundo. Declarar procedente la excepción de mérito formulada por el apoderado de la sociedad demandada.

Tercero. Condenar en costas a Claudia Marcela Gómez Vásquez.

Cuarto. Fijar como agencias en derecho la suma de $1,269,000 a cargo de la parte demandante y a favor de Promotora La Alborada S. A

La anterior providencia se notifica en estrados.

El Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles

José Miguel Mendoza
Nit: 800.169.225
Exp: 26108.
Rad:0.
Trámite: 140009.
Código Dep: 480.
J6866